

1500157-54.2021.8.26.0262

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: FÁBIO APARECIDO TIRONI

Comarca: Itabera

Foro: Foro de Itabera

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 02/02/2022

... com a renda, o que motivou suspeita de tráfico; chegaram a investigar se o réu tinha trabalho lícito; na interceptação não apareceu nada de trabalho lícito; os policiais falavam que ele só vivia de tráfico".

A testemunha DANILO CAMPOLIM DE ALMEIDA, policial civil, declarou em solo policial (fl.03): "Que é Policial Civil dessa DISE e efetuou diligências de investigações que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itabera

Foro de Itabera

Vara Única

Rua Coronel José Pedro de Lima, 266, Itabera - SP - cep 18440-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500157-54.2021.8.26.0262 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500157-54.2021.8.26.0262

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JADERSON RIBEIRO DE ALMEIDA OLIVEIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FÁBIO APARECIDO TIRONI

## I - RELATÓRIO

Trata-se de ação penal pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de JADERSON RIBEIRO DE ALMEIDA OLIVEIRA, já qualificado nos autos em epígrafe (fls.04), que apura a suposta prática do crime tipificado no art.

33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei Federal 10.826/03.

Segundo consta na denúncia de fls. 268-272, no dia 02 de setembro de 2021, numa chácara no Bairro do Saltinho, na cidade e comarca de Itabera, JADERSON RIBEIRO DE ALMEIDA OLIVEIRA, guardava e mantinha em depósito para fins fornecer a qualquer título para terceiros e para a venda, 24 (vinte e quatro) tablets contendo substância entorpecente TETRAHIDROCANNABINOL, vulgarmente conhecida como "maconha" com peso de 13,1 kg (treze quilogramas e cem gramas) e uma porção menor da mesma droga com peso de 12,39 (doze gramas e trinta e nove centigramas) substância essa

que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta ainda que nas mesmas condições de tempo e lugar, JADERSON RIBEIRO DE ALMEIDA OLIVEIRA, qualificado a fls. 04, possuía e mantinha sob sua guarda, no interior da residência, uma espingarda de fabricação artesanal, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Sustentou o Ministério Público que, "(...) o denunciado JADERSON fornecia drogas para diversas pessoas na região de Itaberá. Nestas circunstâncias, na data dos fatos, o denunciado guardava e mantinha em depósito, especificamente no interior do seu veículo e de sua residência substâncias entorpecentes. Ocorre que, o denunciado foi investigado pela policial civil em virtude de envolvimento com o tráfico de drogas e outros delitos em comparsaria com terceiros indivíduos, de modo que foi concedida ordem judicial de busca e apreensão em seu domicílio. Desta feita, por ocasião do cumprimento da medida, o denunciado foi abordado em sua chácara, por policiais civis no cumprimento da ordem de busca, ocasião em que, realizadas buscas em seu veículo, notadamente no porta-malas do automóvel, marca Chevrolet, modelo Corsa de placas AKK-3I23, foi encontrado um saco acondicionando vinte e quatro tabletes de maconha, os quais foram devidamente apreendidos (auto de exibição e apreensão de fls. 16/17). Ao perceber que a droga havia sido encontrada, o denunciado empreendeu fuga, contudo, foi rapidamente detido pelos policiais. Na sequência, realizada busca no imóvel, foram encontrados R\$ 2.000,00 (dois mil reais) em dinheiro, aparelhos celulares e uma espingarda de fabricação artesanal. Em seguida os policiais dirigiram-se até outro endereço do denunciado onde encontraram uma pequena porção de maconha, dois celulares, caderno com anotações manuscritas, típicas de tráfico de drogas, pen drive e uma motocicleta marca Honda, todos eles apreendidos. Inquirido, o denunciado admitiu a propriedade do veículo e da droga encontrada em seu interior. O contexto no qual as drogas foram apreendidas, mormente no que diz respeito a quantidade, a forma que se encontravam armazenada, a tentativa de fuga do denunciado, os demais objetos apreendidos, aliados às notícias da prática delitiva que se somam a investigação pretérita envolvendo o réu, evidenciam claramente que tais entorpecentes se destinavam ao comércio ilícito".

Preso em flagrante no dia dos fatos (fl. 01), o flagrante foi convertido em preventiva no dia seguinte (fls. 69-73).

O Ministério Público ofereceu denúncia em 06.10.2021 (fls. 268-272).

Notificado (fl. 280), o denunciado apresentou defesa preliminar (fls. 283-298).

A denúncia foi recebida por meio de decisão no dia 26.11.2021 (fls. 141-142). Na mesma oportunidade foi designada data da audiência de interrogatório, instrução, debates e julgamento para o dia 02.02.2022.

A Defesa juntou documentos nas fls. 369-409.

Em audiência virtual realizada na forma do Comunicado CG nº 284/2020, bem como com base no permissivo do art. 6º, § 2º da Resolução nº 312/2020 do Conselho Nacional de Justiça, foi produzida prova testemunhal e o réu foi interrogado.

Em alegações finais orais o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia, ao passo que a defesa reiterou as preliminares de ilicitude das provas por violação do juiz natural e por quebra da cadeia de custódia e, subsidiariamente, como tese de mérito, pugnou pelo reconhecimento da minorante do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 com a fixação da pena no regime aberto com substituição por restritiva de direitos e absolvição da imputação do crime do art. 12 do Estatuto do Desarmamento.

É o relatório, no essencial. Passo a fundamentar e a decidir.

## II - FUNDAMENTAÇÃO

### 2.1. Considerações iniciais:

Consigne-se, a título introdutório, que as preliminares arguidas pela Defesa não comportam acolhimento.

Com efeito, o presente feito teve início em decorrência da prisão em flagrante do réu, ocorrida durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo juízo de Itararé-SP.

Do que se extrai das peças dos autos nº 1502880-92.2021.8.26.0279 que foram juntadas no presente feito, as investigações visavam esclarecer supostos crimes de tráfico de drogas na região, sendo o réu, morador desta cidade de Itaberá-SP, um dos alvos (fls. 32-35).

A existência de indícios de conexão dos fatos supostamente praticados pelo réu com os outros investigados residentes na comarca de Itararé tornava aquele juízo aparentemente competente para a análise e deferimento da medida cautelar de busca e apreensão domiciliar, anotando-se que não há que se falar em competência absoluta do local de domicílio do investigado para o deferimento da busca.

Vale ressaltar, sobre outro aspecto, que indícios de conexão não tornam obrigatória a reunião dos processos. Em outras palavras, o suposto crime atribuído ao réu foi praticado nesta cidade e comarca de Itaberá, de modo que aqui deve ser processado e julgado, não havendo razão bastante para que o feito tramite na comarca de Itararé tão somente em razão de a investigação ter lá se iniciado.

Ademais, embora não conste do auto de exibição e apreensão de fls. 16-17 o número do lacre da apreensão da espingarda artesanal, não há que se falar em violação à cadeia de custódia e/ou ilicitude, sobretudo porquanto a defesa não apontou nada de concreto que afastasse a credibilidade do auto de exibição e apreensão de fls. 16-17 e do laudo pericial de fls. 114-116.

A Defesa se limitou a alegar que o número do lacre a arma de fogo em questão somente consta do documento de fl. 101, contudo, não impugna especificamente o laudo pericial da arma e/ou as suas conclusões, nada trazendo aos autos no sentido de que a arma periciada é diversa daquela apreendida na posse do réu e/ou que houve qualquer alteração nas suas características, de modo que a preliminar arguida merece ser rechaçada.

Em sentido semelhante: "(TJSP; Apelação Criminal 1500435-98.2021.8.26.0571; Relator (a): Heitor Donizete de Oliveira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/01/2022; Data de Registro: 31/01/2022)".

Isto posto, REJEITO as preliminares arguidas pela defesa e, por consequência, considero lícitas todas as provas constantes dos autos.

Assim, inexistindo questões preliminares e/ou prejudiciais capazes de inviabilizar a análise do mérito da causa, ou mesmo nulidades que possam macular os atos e o processo como um todo, a questão trazida a juízo merece um provimento jurisdicional de cunho material.

2.2. Da prova testemunhal colhida perante a autoridade policial e em juízo:

A prova testemunhal colhida perante a autoridade policial e produzida durante a instrução em juízo foi no seguinte sentido:

A testemunha ADRIANO FERRAZ FRANSON DE SOUZA, policial civil que realizou a prisão em flagrante do réu, declarou em solo policial (fl. 02): "Que é Policial Civil dessa DISE e participou das diligências com finalidade de identificar o sítio do autuado Jaderson, pois diligências efetuadas pelo policial Danilo davam conta de que esse autuado escondia drogas neste sítio no município de Itaberá/SP, que após essas diligências, Danilo ofertou relatório ao Delegado desta DISE o qual representou por buscas e apreensão no citado sítio e outros imóveis os quais ficam na cidade de Itararé; que o juízo da Primeira Vara do Fórum de Itararé expediu o competente mandado de busca referente ao processo nº 1502880-92.2021.8.26.0279; que na manhã de hoje juntamente com Danilo e outros policiais, foi até o referido sítio para cumprimento da medida citada e ao chegar no local viu o autuado Jaderson e outras pessoas do lado de fora de uma casa; que o autuado foi cientificado da ordem judicial de busca e então iniciaram-se as revistas; que ao abrir o porta malas de um veículo GM Corsa placa AKK-3i23 constatou que no mesmo havia um saco contendo vários tabletas com odor de maconha, que neste momento avisou em voz alta seus colegas sobre o que havia encontrado momento que Jaderson levantou-se e saiu em disparada sendo rapidamente detido por outros policiais que estavam mais próximos a ele; que no local Jaderson admitiu que aquele carro que estava a droga lhe pertencia; além do carro e a droga foram apreendidos dentro da casa uma espingarda artesanal, R\$2.000,00 (dois mil Reais) em dinheiro e quatro telefones celulares, sendo que um deles estava dentro do carro citado; que os tabletas totalizaram 24

tabletes no porta malas; que em ato contínuo foi até a cidade de Itararé para dar cumprimento a busca na casa do autuado Jaderson, diligência que foi acompanhada por Sani que é amazia do autuado; no local encontrou uma pequena porção de erva aparentando ser maconha, dois telefones celulares, um caderno de anotações suspeitas, um pendrive e o veículo Honda City placa FMB-7762, todos devidamente apreendidos”.

Em juízo relatou que: “o Jaderson já estava sendo investigado pela delegacia; tinham informação de que o paradeiro dele, junto com a droga, era uma chácara em Itaberá; fizeram diligências iniciais e confirmaram essa informação; representaram pela busca e apreensão; no local estava o réu e seus familiares; inicialmente o réu negou a posse de qualquer ilícito; o depoente encontrou as drogas no veículo; também encontraram celulares e a arma de fogo; quando encontrou as drogas o réu tentou fugir; a arma ele falou que era da casa, ele falou que não funcionava; não deu para testar na hora; ele falou que a droga era apenas dele e que mais ninguém sabia da existência no local; ninguém mais da casa falou algo; para Itaberá era muito, provavelmente essa droga estava sendo vendida em Itararé; na investigação surgiram outras pessoas; não se recorda se foram encontradas balanças ou outros objetos na chácara, acredita que não; também foi feita busca na residência do réu na cidade de Itararé; também foi feita busca na casa do irmão do réu; não se recorda da outra pessoa; essa investigação teve interceptação telefônica; todos os investigados eram de lá; em relação a essa droga não foi apurada a participação de outras pessoas; foi apurado apenas que ele trouxe de Itararé; não foi apurado nada sobre destinação; as drogas estavam no veículo GM CORSA HATCH de placas AKK-2I23; ele usava provavelmente para transportar as drogas; o outro veículo foi apreendido em razão da incompatibilidade com a renda, o que motivou suspeita de tráfico; chegaram a investigar se o réu tinha trabalho lícito; na interceptação não apareceu nada de trabalho lícito; os policiais falavam que ele só vivia de tráfico”.

A testemunha DANILO CAMPOLIM DE ALMEIDA, policial civil, declarou em solo policial (fl.03): “Que é Policial Civil dessa DISE e efetuou diligências de investigações que davam conta de que o Jader continha um sítio e escondia drogas neste sítio no município de Itaberá/SP; que juntamente com o Policial Civil Adriano realizou diligências para identificar tal sítio; que após essas diligências, o depoente ofertou relatório ao Delegado desta DISE o qual representou por buscas e apreensão no citado sítio e outros imóveis os quais ficam na cidade de Itararé; que o juízo da Primeira Vara do Fórum de Itararé expediu o competente mandado de busca referente ao processo nº 1502880-92.2021.8.26.0279; que na manhã de hoje juntamente com Adriano e outros policiais, foi até o referido sítio para cumprimento da medida citada e ao chegar no local viu o autuado Jaderson e outras pessoas do lado de fora de uma casa; que o autuado foi cientificado da ordem judicial de busca e então iniciaram-se as revistas; que o Policial Civil Adriano abriu o porta malas de um veículo GM Corsa placa AKK-3i23 e constatou que no mesmo havia um saco contendo 24 tabletes com odor de maconha, que neste momento Adriano avisou em voz alta para o depoente e seus colegas sobre o que havia encontrado momento que Jaderson levantou-se e saiu em disparada sendo rapidamente detido por outros policiais que estavam mais próximos a ele; que no local Jaderson admitiu que aquele carro que estava a droga lhe pertencia; além do carro e a droga foram apreendidos dentro da casa uma espingarda artesanal, R\$2.000,00 (dois mil Reais) em dinheiro e quatro telefones celulares, sendo que um deles estava dentro do carro citado; que os tabletes totalizaram 24 tabletes no porta malas; que em ato contínuo foi até a cidade de Itararé para dar cumprimento a busca na casa do autuado Jaderson, diligência que foi acompanhada por Sani que é amazia do autuado; no local encontrou uma pequena porção de erva aparentando ser maconha, dois telefones celulares, um caderno de anotações suspeitas, um pendrive e o veículo Honda City placa FMB-7762, todos devidamente apreendidos”.

ANTONIO BARSOTTI afiançou que: “o depoente é professor aposentado; conhece o réu há um bom tempo, cerca de 05, 06, 07 anos mais ou menos; o réu já trabalhou para o depoente, como pedreiro; ele trabalhou em uma construção na frente da casa do depoente; para o depoente ele só trabalhou nessa construção; tinha outro serviço contratado com ele; já viu o depoente fazer duas casas em outro lugar; ele é um

ótimo pedreiro; a última vez que o réu trabalhou para o depoente foi no ano passado, por volta de maio, junho ou julho; ele recebia em média de R\$ 100,00 por dia; nunca ouviu falar que o réu era traficante de drogas”.

LINDOMAR RODRIGUES asseverou que: “trabalha com gado, frete, sítio, chácara; conhecia o réu há cerca de um ano e meio; o réu já trabalhou para o depoente; ainda tem trabalho para ele; o depoente também foi objeto do mandado de busca e apreensão; chegou o bando de polícia na casa do depoente, apontando arma; inicialmente achou que era brincadeira; eles perguntaram do réu; o depoente contou que ele trabalhava no local, que ia quase todo dia lá; o policial falava do 'veio', mas o depoente falou que não tinha esse apelido; eles falavam que tinha droga no local; o depoente não sabia que ele mexia com isso; eles colocaram cachorro para procurar drogas; o réu estava fazendo duas obras para o depoente; é um bom pedreiro; os policiais pegaram os celulares do depoente; o depoente autorizou destravar e ver o conteúdo; eles averiguaram e devolveram; nunca ouviu falar que o réu era envolvido com tráfico”.

Em seu interrogatório perante a Autoridade Policial o acusado JADERSON RIBEIRO DE ALMEIDA OLIVEIRA exerceu o direito constitucional ao silêncio (fls. 04-05).

Interrogado em juízo, por sua vez, confessou a prática dos fatos narrados na denúncia: “a acusação é verdadeira; pegou as drogas para transportar; era a terceira vez que transportava; transportou uma vez em Taquarituba; uma vez em Riversul; e dessa vez ia entregar em Coronel Macedo; recebia R\$ 2.000,00 por carga; é o valor que pegaram no dia com o depoente; é um rapaz de Itararé que contratou o depoente; não pode falar que contratou; ele avisava onde estava a droga e o depoente; sempre que ia pegar a droga o dinheiro já estava junto; sempre deixava na beira da pista, em marcação que eles falavam; transportava no carro, no GM Corsa placa AKK-3i23; esse carro era do depoente; é do rolo, tinha comprado esse carro do rolo, o carro não está no nome do depoente; não lembra no nome de quem está; Honda City placa FMB-7762 era da irmã do depoente, não o utilizou para transportar drogas; ele deixou para o depoente vender; o carro está com ela de volta; a arma é antiga, é de família; o avô faleceu e deixou na casa; o depoente pegou na casa dele e levou para o sítio; ela nunca foi usada; se envolveu com drogas porque a pandemia enfraqueceu o serviço do depoente e o seu pai estava com problemas de saúde; o sítio é do pai do depoente”.

Após a exposição da prova testemunhal, passo a analisar, individualmente, as acusações formuladas em face do réu.

### 2.3. Do suposto crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33):

De início, é sabido que o tipo objetivo do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade consciente) de praticar o comércio ilícito. O objeto material é a droga, o jurídico é a saúde pública. Na situação ora em apreço, consigne-se, desde já, que as provas constantes dos autos são bastantes a fundamentar um juízo condenatório.

Com efeito, o auto de exibição e apreensão de fls. 16-17 demonstra que foram apreendidas na posse do réu 13.540 gramas, isto é, 13,45 quilos da substância vulgarmente conhecida como maconha, acondicionadas em 24 “tijolos”, além de 13,62 gramas da mesma substância acondicionada em uma porção, bem como aparelhos celulares, veículos e um caderno/bloco contendo anotações possivelmente relacionados ao tráfico de drogas.

Anote-se que, conforme conclusões dos laudos periciais preliminares de fls. 38-41 e 42-43, bem como os laudos de Exame Químico-Toxicológico - Laudos Definitivos de fls. 106-109 e 110-113, constatou tratar-se de substância entorpecente as matérias apreendidas (art. 50, § 1º, da Lei nº 11.343/06), qual seja, maconha (TETRAHIDROCANNABINOL- THC).

Referidas provas demonstram, além de qualquer dúvida razoável, a materialidade do crime de tráfico de drogas.

Do mesmo modo que a materialidade, a autoria encontra-se devidamente comprovada nos autos, já que o conjunto probatório demonstra além de qualquer dúvida razoável que o acusado JADERSON RIBEIRO DE ALMEIDA OLIVEIRA foi o autor do crime descrito na denúncia, conforme será devidamente demonstrado a seguir.

Com efeito, as provas colhidas durante a instrução processual e elementos informativos angariados na fase inquisitorial são bastantes a fundamentar um juízo condenatório.

Com efeito, os Policiais Civis ADRIANO FERRAZ FRANSON DE SOUZA e DANILO CAMPOLIM DE ALMEIDA, de forma harmônica e coerente, relataram com detalhes a diligência realizada na residência do réu que culminou com a apreensão de expressiva quantidade de drogas que estavam armazenadas em um veículo.

Some-se a isso o fato de que as drogas foram apreendidas no imóvel do réu e em seu veículo, tendo ele relatado no momento da prisão, segundo depoimento do policial civil, que as drogas lhes pertenciam.

Ademais, o Policial Civil ADRIANO FERRAZ FRANSON DE SOUZA confirmou que o réu já era investigado pela prática do crime de tráfico de drogas, suspeita esta que se confirmou com a apreensão dos mais de 13kg de maconha objeto da presente ação penal.

Além disso, o réu confessou a autoria do crime de tráfico de drogas, admitindo que recebeu R\$ 2.000,00 para transportar as drogas em questão da cidade de Itararé até Coronel Macedo, sustentando que foi a terceira vez que ele fez esse tipo de transporte.

Por conseguinte, dos depoimentos acima transcritos se extrai, além de qualquer dúvida razoável, que a droga apreendida era de propriedade do réu e destinada ao tráfico.

Ademais, as circunstâncias do encontro das substâncias entorpecentes, além do que já se expôs, geram a convicção da posse voltada para o comércio e não a finalidade para o uso próprio.

Vale ressaltar, sobre outro aspecto, que eventual exercício cumulativo da traficância com atividade lícita não afasta a responsabilidade penal do réu nem evidencia que ele não era dedicado a atividades criminosas, porquanto essa dedicação ao crime não precisa ser exclusiva, isto é, o tráfico não necessita ser o único meio de vida do réu para a caracterização dessa circunstância.

No que tange ao depoimento de policiais, ressalta-se não existir dispositivo legal vedando ao agente público servir como testemunha. Além disso, não se acredita que servidores públicos, inclusive os policiais, empossados que são após compromisso de fielmente cumprirem seus deveres, apresentariam testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de inculpar inocentes. Ao contrário, têm os funcionários públicos a presunção de que no desempenho de suas atuações agem escorreitamente.

Importante ressaltar que o policial é testemunha como outra qualquer, já que não figura entre os impedidos ou suspeitos, sujeitando-se ao compromisso de dizer apenas a verdade, sob as penas do falso testemunho. Ademais, nos casos de tráfico de drogas, onde o testemunho civil é quase sempre impossível, deve ser conferido às declarações do policial o merecido valor em confronto com os demais elementos de convicção trazidos aos autos.

Nessa linha de raciocínio, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que “o valor do depoimento testemunhal de servidores públicos especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC nº 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).

O Superior Tribunal de Justiça, da mesma forma, entende que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal”. (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma).

Vale ressaltar, outrossim, que nada de concreto foi trazido pela defesa que afastasse a credibilidade dos depoimentos dos Policiais Civis, servidores públicos que sequer conheciam o réu.

Ademais, as circunstâncias do encontro das substâncias entorpecentes, além do que já se expôs, geram a convicção da posse voltada para o comércio e não a finalidade para o uso próprio. Nessa mesma ordem de ideias, conforme trecho do v. acórdão

proferido na Apelação nº 0000926-20.2016.8.26.0616, "Por outro lado, o crime de tráfico de entorpecentes é de perigo abstrato, punindo-se a conduta pelo risco que ele representa para a saúde pública, de modo que não há necessidade de efetiva prática de ato de comércio, bastando que o agente seja apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em depósito substância entorpecente com finalidade de venda". (TJSP; Apelação 0000926-20.2016.8.26.0616; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itaquaquetuba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/07/2018; Data de Registro: 03/08/2018).

Ainda, em consonância com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para a caracterização do crime de tráfico e drogas prescinde que o réu seja surpreendido no momento da realização da mercancia da droga, especialmente porque o tipo penal é misto alternativo e a prática de qualquer conduta do núcleo do tipo caracteriza do delito. A propósito: "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente." (TJSP - AC 20.239 - Rei. Geraldo Gomes-RT 584/347); "TÓXICOS - Tráfico - Prova de algum ato de comércio - Desnecessidade - Trazer consigo ou manter a droga em depósito para venda, ainda que futura - Suficiência, na medida em que a consumação do delito não exige qualquer resultado Recurso parcialmente provido para reduzir as penas impostas e estabelecer o regime inicial fechado." (Apelação Criminal n. 1.141.860-3/6 São Paulo 5ª Câmara Criminal Relator: Pinheiro Franco 14.02.08 V.U. Voto n. 10.277).

Nesse cenário, de rigor a condenação do réu nos termos do art. 33 da Lei 11.343/06. 2.4. Do suposto crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei 10.826/03, art. 12):

A materialidade do crime corresponde à prova de sua existência, em outras palavras, são os elementos que demonstra a ocorrência/existência do delito.

Na situação sob julgamento a materialidade delitiva do delito de posse de arma restou devidamente comprovada pelo do auto boletim de ocorrência de fls. 07-015, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 16-17, em especial na parte em que demonstra a apreensão de uma arma de fogo artesanal de uso permitido, em bom estado de conservação.

Além disso, o laudo pericial de fls. 114-116 concluiu que se trata de uma "arma de fabricação artesanal e de retrocarga", com "diâmetro da boca do cano de 12mm", "não municada", "sem número de série e, sobretudo, "foi constatado que seus mecanismos de armação, percussão e disparo se encontravam operante, ou seja, a arma estava APTA à realização de disparos".

A autoria, da mesma forma, é conhecida e certa, recaindo sobre o réu JADERSON RIBEIRO DE ALMEIDA OLIVEIRA, conforme se extrai dos depoimentos dos Policiais Civis ADRIANO FERRAZ FRANSON DE SOUZA e DANILO CAMPOLIM DE ALMEIDA.

Destaque-se que o réu confessou a autoria a autoria do crime em questão, admitindo que possuía a arma, a qual ficou sob a sua responsabilidade após o falecimento do avô. Em outras palavras, não merece acolhimento a tese defensiva no presente ponto, uma vez que o réu era sim o responsável pela posse da arma, tanto que ele próprio admitiu em seu interrogatório que levou a arma para o sítio após o falecimento do avô.

Anote-se que não há que se falar em atipicidade da conduta, uma vez que foi apreendida na posse do réu uma arma de fogo em bom estado de conservação e apta a efetuar disparos (fls. 16-17 e 114-116), valendo registrar que o crime do art. 12 do Estatuto do Desarmamento é de perigo abstrato e se consuma mesmo no caso de apreensão isolada de munição e/ou de arma desmunicada.

Nesse sentido, aliás, decide reiteradamente o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: "POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES (USO PERMITIDO). Recurso defensivo.

ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Atipicidade. Inocorrência. Infração de perigo abstrato, que se consuma com a simples posse, sem a necessidade de que esteja acompanhada da arma. DOSIMETRIA. Penas e regime

preservados. IMPROVIMENTO". (TJSP; Apelação Criminal 0016460-83.2012.8.26.0344; Relator (a): Eduardo Abdalla; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Marília - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021); "POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. Recurso defensivo.

Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Atipicidade. Inocorrência. Infração de perigo abstrato, que se consuma com a simples posse, sem a necessidade de que esteja acompanhada da arma. Precedentes jurisprudenciais.

Dosimetria. Afastamento da reincidência. Reconhecimento da atenuante da confissão.

Inteligência da Súmula/STJ, nº 545. Penas diminuídas. Possibilidade de regime aberto. Inaplicabilidade do CP, arts. 44 ou 77. Provimento parcial". (TJSP; Apelação Criminal 0000638-72.2017.8.26.0540; Relator (a): Eduardo Abdalla; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/02/2019; Data de Registro: 15/02/2019).

Da mesma forma já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça: "(...) é irrelevante aferir a eficácia da arma, apreender sua munição ou verificar se os cartuchos em seu interior estariam deflagrados para a configuração do tipo penal, que é mistoalternativo, em que se consubstanciam, justamente, as condutas que o legislador entendeu por bem prevenir, seja ela o simples porte de munição ou mesmo o porte de arma desmuniçada (...)" (STJ, AgRg no REsp 1460899/MG, Sexta Turma, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 19/09/2014).

Assim, de rigor a condenação do réu também pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03.

#### 2.5. Considerações finais:

À vista de todos esses elementos, conclui-se que o réu JADERSON RIBEIRO DE ALMEIDA OLIVEIRA, com consciência e vontade, isto é, agindo dolosamente, praticou os fatos descritos na denúncia, conduta esta que se amolda formal e materialmente ao tipo do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e ao tipo do art. 12 da Lei 10.826/03, ambos em concurso material (CP, art. 69).

Conforme a teoria da indiciabilidade ou da ratio cognoscendi, acolhida pela doutrina majoritária e pela legislação processual, a tipicidade funciona com um indício da ilicitude, razão pela qual cabe ao réu trazer aos autos ao mesmo a dúvida fundada quanto à presença de uma causa de justificação, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

No caso sob julgamento, contudo, o réu sequer alegou a existência de causas excludentes da ilicitude.

Assim, sendo a tipicidade indiciária da ilicitude e não havendo causas excludentes desta, configurado está o injusto penal.

Quanto à culpabilidade, está analisada à luz da teoria normativa pura, de viés finalista, como reprovabilidade do injusto ao autor, composta dos elementos imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, do mesmo modo, inexistem nos autos qualquer elemento que possa afastá-la. Destaco que o réu sequer suscitou a existência de dirimentes.

Desse modo, tem-se que a culpabilidade está presente, porquanto o réu é imputável e dotado de potencial consciência da ilicitude, bem como lhe era exigível conduta diversa.

Assim, comprovadas a materialidade, a autoria, a tipicidade e inexistindo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a condenação do réu JADERSON RIBEIRO DE ALMEIDA OLIVEIRA, pela prática dos crimes tipificados no art.

33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no art. 12 da Lei 10.826/03, ambos em concurso material (CP, art. 69).

#### 2.6. Dosimetria:

Fixadas tais premissas, passo à dosimetria da pena, em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI), bem como do critério trifásico adotado pelo Código Penal (art. 68).

Vale ressaltar que os crimes praticados em concursos tiveram as mesmas circunstâncias, razão pela qual será feita apenas uma dosimetria, destacando-se eventual circunstância diferenciadora, anotando-se que referida sistemática encontra-se em consonância com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. A propósito: "Observadas todas as três etapas da dosimetria, em relação a



cada um dos delitos, separadamente ou não, sendo feitas as devidas diferenciações quando necessárias ou realizadas em conjunto para todos os delitos, quando aplicáveis, não há falar em ofensa ao princípio da individualização da pena pelo aproveitamento dos fundamentos, sem a necessidade de repetição, para evitar tautologia". (HC 285.530/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017).

Das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.343/06: a) Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. No caso em apreço, é inerente ao tipo penal; b) Antecedentes: trata-se de acusado sem antecedentes criminais na forma da Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não poderá ser considerada negativa; c) Conduta social: não há nos autos elementos suficientes para avaliar a vida do acusado em seu ambiente familiar e social, razão pela qual a circunstância não pode ser valorada negativamente; d) Personalidade do agente: não há elementos nos autos que permitam avaliar a personalidade do réu, razão pela qual também não se pode valorá-la negativamente; e) Motivos do crime: os motivos do crime são aqueles inerentes ao tipo e suas circunstâncias não fogem do ordinário; f) Circunstâncias do crime: as circunstâncias em que o crime foi praticado não excedem o que se espera em condições normais; g) Consequências do crime: do mesmo modo as consequências, que são aquelas que se devem ordinariamente esperar do crime em questão; h) Comportamento da vítima: trata-se de crime sem vítima determinada, motivo pelo qual tal circunstância será valorada como neutra; i) Natureza e a quantidade da droga: a presente circunstância deve ser valorada negativamente em relação ao crime de tráfico, uma vez que foi apreendida na posse do réu expressiva quantidade de drogas, consistente em mais de 13 quilogramas de maconha, em evidente indicativo da elevada gravidade em concreto da conduta. Assim, sendo uma circunstância negativa em relação ao crime de tráfico (natureza e quantidade da droga) e ausentes circunstâncias negativas em relação ao crime de posse de arma, fixo a pena-base em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa para o crime do art. 33 da Lei 11.343/06 e 01 mês de detenção e 10 dias-multa para o crime do art. 12 da Lei 10.826/03.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes a serem consideradas. Presente, contudo, a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, "d"), razão pela qual atenuo a pena-base e fixo a pena intermediária em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa para o crime do art. 33 da Lei 11.343/06 e 01 mês de detenção e 10 dias-multa para o crime do art. 12 da Lei 10.826/03 (STJ, Súmula nº 231).

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, não sendo o caso de aplicação da mirante do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, sobretudo diante da evidente dedicação do réu a atividades criminosas, conforme se infere, dentre outros elementos, dos depoimentos dos Policiais Cíveis ADRIANO FERRAZ FRANSON DE SOUZA e DANILO CAMPOLIM DE ALMEIDA que comprovam que JADERSON se dedica a atividades criminosas, tanto que ele responde a processo criminal em outra comarca com a imputação de associação para o tráfico de drogas (autos nº 1501506-68.2021.8.26.0270) e admitiu que era a terceira vez que realizava o transporte de drogas. Vale ressaltar, sobre outro aspecto, que eventual exercício cumulativo da traficância com atividade lícita não afasta a responsabilidade penal do réu nem evidencia que ele não era dedicado a atividades criminosas, porquanto essa dedicação ao crime não precisa ser exclusiva, isto é, o tráfico não necessita ser o único meio de vida do réu para a caracterização dessa circunstância.

Tendo em vista a prática dos crimes em concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, aplica-se, cumulativamente, as penas calculadas, devendo a detenção ser executada posteriormente à reclusão (CP, art. 76).

Considerando que o tempo de prisão provisória não alteraria o regime prisional, deixo de realizar a detração (CPP, art. 387), devendo eventual progressão de regime ser analisada pelo juízo da execução, sobretudo diante da necessidade de aferir a presença dos requisitos subjetivos.

Impede salientar, por fim, que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que são inconstitucionais as previsões da Lei 11.343/06

que impõem a adoção obrigatória do regime inicial fechado e a vedação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, devendo serem observadas as regras do Código Penal quanto ao ponto. Assim, nos termos dos art. 33, §§2º e 3º do Código Penal, e levando em consideração a quantidade de pena e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma legal, notadamente a elevada gravidade em concreto da conduta em razão da grande quantidade de drogas apreendidas, somada com a evidente dedicação do réu à atividade criminosa do tráfico de drogas, fixo o regime FECHADO para o início do cumprimento da pena de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas e o ABERTO para o cumprimento da pena de detenção.

Diante da quantidade da pena, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão de sursis (CP, arts. 44 e 77).

### III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva veiculada na denúncia para o fim de CONDENAR o réu JADERSON RIBEIRO DE ALMEIDA OLIVEIRA pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 às penas de 05 anos de reclusão a ser cumprida no regime inicial fechado e ao pagamento de 500 dias-multa no valor individual de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, bem como pela prática do crime tipificado no art. 12 da Lei 10.826/03 à pena de 01 ano de detenção no crime inicial aberto e ao pagamento de 10 dias-multa no valor individual de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, ambos em concurso material (CP, art. 69), com execução inicialmente da pena de reclusão e posteriormente a de detenção (CP, art. 76).

### IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1. CONDENO o sentenciado ao pagamento das custas processuais (CPP, art. 804).

4.2. Conforme a determinação do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, diante da subsistência dos motivos já expostos nas decisões anteriores e por entender presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada. Com efeito, o fumus commissi delicti decorre da própria procedência da pretensão punitiva veiculada na denúncia, havendo prova da materialidade e indícios de autoria do crime atribuído ao réu. O periculum libertatis, por sua vez, é evidenciado pela gravidade em concreto do crime praticado pelo réu, da possibilidade concreta de o réu voltar a delinquir, bem como da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que não existem garantias de que em liberdade não se afastará do distrito da culpa. . Isto posto, EXPEÇA-SE guia de execução provisória. Além disso, ANOTE-SE a revisão da prisão no sistema SAJ, notadamente para futura reapreciação, devendo a Serventia observar o disposto no COMUNICADO CG nº 78/2020.

4.3. Considerando a demonstração de que o dinheiro apreendido é produto do crime de tráfico de drogas, tanto que o próprio réu admitiu em seu interrogatório que os valores foram recebidos como pagamento para realizar o transporte das drogas, com fundamento no art. 91, II, "b", do Código Penal c/c art. 63, I, da Lei 11.343/06, como efeito secundário da condenação, DECRETO o perdimento em favor da União dos valores apreendidos nas fls. 16-17. Com o trânsito em julgado da presente sentença, PROCEDA-SE a reversão da quantia em favor do FUNAD.

4.4. Ademais, tendo em conta que o veículo GM CORSA HATCH de placas AKK-2I23 foi utilizado para a traficância, uma vez que as drogas apreendidas estavam armazenadas no seu interior conforme relatado pelos policiais civis e confessado pelo próprio réu, com fundamento no art. 91, II, "b", do Código Penal c/c art. 63, I, da Lei 11.343/06, como efeito secundário da condenação, DECRETO o perdimento em favor da União do veículo em questão. Anote-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 638.491/PR sob a temática da repercussão geral (Tema 647), fixou a tese de que "É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da

Constituição Federal." (Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJ 23/8/2017). Ademais, "(...) A expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão em foro constitucional, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição da República, e decorre da sentença penal condenatória, conforme regulamentado, primeiramente e de forma geral, no art. 91, II, do Código Penal, e, posteriormente, de forma específica no art. 63 da Lei n. 11.343/2006. Assim, havendo as instâncias de origem concluído pela utilização do veículo para os fins de tráfico de entorpecentes e, por conseguinte, determinado sua expropriação, não há como esta Corte Superior concluir em sentido contrário, porquanto demandaria a imersão vertical no acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível na via processual eleita(...)". AgRg nos EDcl no REsp 1866666/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020). Com o trânsito em julgado da presente sentença, PROCEDA-SE a reversão do bem em favor do FUNAD.

4.5. Em relação ao veículo HONDA/CITY de placas FMB-7762, por outro lado, nada consta desses autos acerca da sua vinculação ao tráfico de drogas objeto de apuração neste processo, de modo que não é o caso de perdimento.

4.6. DEIXO DE ARBITRAR o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, previsto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, diante da ausência de pedido expresso acerca do montante a ser ressarcido, bem como, por consequência, da ausência de contraditório acerca da matéria.

4.7. COMUNIQUE-SE a condenação ao IIRGD (art. 393, V, das NSCGJ), e com o trânsito em julgado intime-se o réu para pagamento das custas judiciais (art. 479, das NSGCJ). Infrutífera a intimação ou não efetuado o pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE Certidão de Sentença, extraída na forma do artigo 164 da Lei nº 7.210/84 e artigos 479-B e 480-A das NSCGJ. Expedida a Certidão, DÊ-SE VISTA ao Ministério Público, para que, querendo, proponha a competente ação de execução da pena de multa na Vara das Execuções Criminais. Após, deverá a z. Serventia lançar a movimentação "Cód. 62050 - Autos no Prazo - Execução da Multa Penal". I. Comunicado pelo Juízo da Execução o ajuizamento da ação de execução da multa penal, deverá a z. Serventia proceder à anotação no histórico de partes do evento "Cód. 17 - Início da Execução da Pena de Multa", indicando no complemento o número do processo de execução e lançando a movimentação "Cód. 61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação", arquivando-se a seguir. II. Não havendo comunicação pelo Juízo da Execução o ajuizamento da ação de execução da multa penal, aguarde-se o transcurso do lapso prescricional. Após, volvam-me os autos cls. para declaração da extinção da pena.

4.8. DETERMINO a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas (art. 72, da Lei nº. 11.343/2006), caso a providência já não tenha sido adotada.

4.9. Oficie-se ao INI, ao IIRGD, à VEC e ao TRE (art. 398, II, das NSCGJ).

4.10. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Itabera, 01 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA